

刑法第109条第2項及び同法第110条の「公共の危険」に関して、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの()内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A. 刑法第109条第2項及び同法第110条の「公共の危険」の内容について、どう考えますか。

学生B. 私は、「公共の危険」は、①(a. 刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険・b. 刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険に限らず、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険)をいうと考えます。このように考えれば、刑法第111条第1項が、同法第109条第2項及び同法第110条第2項の結果的加重犯として同法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼を処罰していることと符合すると考えます。

学生A. この点についてのBさんの考えは、判例と同じですか。

学生B. 私は、判例に②(c. 賛成・d. 反対)する立場です。ところで、Aさんは、「公共の危険」の認識が必要かどうかは、どう考えますか。

学生A. 私は、刑法第109条第2項の「公共の危険」の発生を③(e. 構成要件の状況・f. 客観的処罰条件)と解し、同法第110条の「公共の危険」の発生を④(g. 違法性を基礎付ける要素・h. 結果的加重犯の加重的結果)と解しますので、「公共の危険」の認識を⑤(i. 必要・j. 不要)と考えます。

学生B. そうでしょうか。私は、自己所有物の焼損は本来違法行為ではなく、「公共の危険」の発生によって初めて犯罪となると考えるので、Aさんの見解に反対です。それに、Aさんの見解では、⑥(k. 「公共の危険」の認識と、刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険の認識との区別が困難となる・l. 刑法第110条第1項の客体の焼損の認識のみでは器物損壊罪の責任しか基礎付けられない)ではありませんか。この点、判例はどのような立場を採っていますか。

学生A. 判例は、刑法第110条第1項の「公共の危険」の認識を⑦(m. 必要・n. 不要)としていますね。

1. ①a ②d ⑤j ⑥l
2. ①b ③e ④g ⑥k
3. ②c ④h ⑤j ⑦m
4. ②d ③f ⑥k ⑦n
5. ③f ④h ⑤j ⑦m

No351

公共の危険

正答率

R6-17

正解

1

45%

() には順に、「① = a、② = d、③ = f、④ = h、⑤ = j、⑥ = l、⑦ = n」と入り、したがって、正解は肢1となる。

司法試験平成19年第3問と似た出題だが、問題文中には各条数と「公共の危険」「延焼」等という言葉があるにとどまり、罪名が示されず放火という文字も隠されている。基本的な条文知識、論点知識を前提とした出題で、平成19年よりも難易度は上がっている。基本書、百選掲載判例とともに、条文構造や整理した知識が必要とされている。

108条 : 現住建造物等放火罪

109条1項: 非現住建造物等放火罪

2項: 自己所有非現住建造物等放火罪

110条1項: 建造物等以外放火罪

2項: 自己所有建造物等以外放火罪

111条1項: 109Ⅱ・110Ⅱから108・109Ⅰへの延焼罪

2項: 110Ⅱから110Ⅰへの延焼罪

①について

①に続く学生Bの発言では「このように考えれば、刑法第111条第1項が、同法第109条第2項及び同法第110条第2項の結果的加重犯として同法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼を処罰していることと符合する」としている。このことから、「公共の危険」の内容は「a. 刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険」であるとするのが自然である。したがって、①には、「a. 刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険」が入る。

②について

最決平15.4.14(百選Ⅱ85事件)は、「公共の危険」の意義について、「必ずしも同法〔刑法〕108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である」と述べている。したがって、学生Bの立場は判例に反対する立場であるといえるから、②には「d. 反対」が入る。

⑤について

⑤に続く学生Bの発言では、「私は、自己所有物の焼損は本来違法行為ではなく、『公共の危険』の発生によって初めて犯罪となると考える」と述べている。これは、公共の危険の認識が必要であるとする立場からの主張である。Bは、これに続けて、「Aさんの見解に反対です。」と述べているから、学生Aは、学生Bと対立する立場にあると考えられるため、⑤には「j. 不要」が入る。

③について

「公共の危険」の認識を不要とする立場は、109条2項の「公共の危険を生じなかったとき」は「罰しない」という文言から、同項の「公共の危険」の発生が客観的処罰条件と解されることを理由としている。したがって、③には「f. 客観的処罰条件」が入る。

④について

「公共の危険」の認識を不要とする立場は、110条1項が「よって」という文言を用いていることから、同条の「公共の危険」の発生が結果的加重犯の加重的結果と解されることを理由としている。したがって、④には「h. 結果的加重犯の加重的結果」が入る。

⑥について ★

学生Bの発言には、認識不要説を批判する内容が入る。「公共の危険」の認識を必要とする立場からは、110条1項が器物損壊よりも重い公共危険罪を構成する理由は、具体的な公共の危険の発生にあるのであるから、その認識を必要と解すべきであるとされ、認識不要説に対し、110条1項の客体の焼損の認識のみでは器物損壊罪の責任しか基礎付けられないとの批判がされている。したがって、⑥には「l. 刑法第110条第1項の客体の焼損の認識のみでは器物損壊罪の責任しか基礎付けられない」が入る。なお、「k. 『公共の危険』の認識と、刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険の認識との区別が困難となる」の内容は、公共の危険の認識必要説に対する批判である。

⑦について

最判昭60.3.28（百選Ⅱ86事件）は、「刑法110条1項の放火罪が成立するためには、火を放って同条所定の物を焼燬する認識のあることが必要であるが、焼燬の結果公共の危険を発生させることまでを認識する必要はない」と判示し、認識不要説に立っている。したがって、⑦には、「n. 不要」が入る。